

1500684-20.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... M.P entendeu que deve ser afastado o tráfico privilegiado em razão da quantidade de drogas.

Há que se considerar que nos casos em que o autor do crime é considerado "mula" do tráfico, que foi contratado para transporte único, a jurisprudência do STJ e do STF é no sentido que apenas a grande quantidade de drogas, não conduz à conclusão de que integre ou se dedique a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500684-20.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500684-20.2022.8.26.0537

2022/000567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE AZAMBUJA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

FILIPPE AZAMBUJA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 07 de abril de 2022, por volta das 11: 00 horas, na praça de pedágio do Km 16 da Rodovia dos Imigrantes, bem como na Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível e na Rua Parapuã, altura do n.º 02, esquina com a Av. Conceição, Centro, adquiriu, guardou e transportou, para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que o delito foi perpetrado entre diferentes Estados da Federação.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 45/49).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 117/127), sendo recebida a denúncia em 05.09.22 (fls. 139/140). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela grande quantidade de droga, afastando-se a redução do art. 33, §4.º, fixação de regime fechado e perdimento do veículo apreendido.

O defensor do réu requereu que seja considerada a confissão judicial, a redução do art. 33,§4.º, que seja afastado o tráfico interestadual, a detração para fixação de regime inicial e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 05/06), o acusado negou a prática do crime. Informou que reside em São José dos Pinhais, Estado do Paraná. Disse que o serviço no município estava "fraco" e comentou com alguns amigos que viria para a cidade de São Caetano do Sul, neste Estado, visitar um tio, pois em São Paulo era mais fácil conseguir fretes. Então, um dos amigos, conhecido por "Paulinho", que também possui uma van, propôs que entregasse 3 caixinhas em São Paulo, pelo que lhe pagaria R\$ 200,00. Falou que aceitou a proposta de "Paulinho" e que este colocou as 3 caixas na van, entregou uma nota fiscal de peças e disse que quando chegasse em São Paulo passaria o local da entrega. Não questionou o conteúdo das 3 caixas, nem porque o endereço da entrega não era o mesmo da nota, apenas aceitou o serviço e transportou as caixas. Relatou que quando passava pelo pedágio nesta cidade percebeu uma viatura vindo logo atrás da van, mas pensou que não era com ele e continuou dirigindo, até ser fechado e abordado. Narrou que os policiais o questionaram sobre o que estava transportando e ao verificarem as caixas localizaram drogas. Afirmou não saber que estava transportando drogas. Informou que a van Peugeot/Boxer de placas EZQ4H65 pertence a ele, mas está em nome de seu pai.

Em juízo, confessou a prática do crime. Falou que passou com a Van no sem parar e quando os policiais deram ordem de parada, estacionou. A nota fiscal é de um equipamento que fez transporte antes. Confessou para os policiais que transportava drogas (de Presidente Prudente para Diadema). Disse que estacionou no Frango Assado, como orientado, quando parou um veículo e o ocupante mandou seguir, que ia descarregar em Diadema. Falou que ia ganhar R\$5.000,00 para transportar as drogas. Trabalhava com transporte de cargas, com firma aberta. Abriu uma loja de celular e um rapaz ficou trabalhando para ele com o Furgão, mas como não estava sobrando lucro deste, resolveu vender aquela. Depois devia dinheiro para um agiota e fez o transporte das drogas para pagar para este. Nunca foi processado. Tem 38 anos. Está arrependido. Mora em São José dos Pinhais no Paraná.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/04), disseram que por meio de investigações obtiveram a informação de que um veículo Peugeot/Box de cor branca, placas EZQ4H65, estava transportando drogas para abastecer o tráfico no município. Relataram que diligenciaram até a praça de Pedágio da Rodovia dos Imigrantes (Km 16), que dá acesso a Diadema, e por volta das 11:00 horas, se depararam com o veículo informado e passaram a acompanhá-lo, até verificarem o melhor momento para realizar a abordagem. Afirmaram que o motorista (réu) acelerou ao perceber que estava sendo acompanhado e tentou se evadir. Narraram que quando o veículo transitava na esquina da Av. Conceição com a Rua Parapuã, no Centro do município, deram sinal de parada e abordaram o condutor do Peugeot/Box. Identificaram o motorista do veículo como sendo o réu, o qual afirmou que estava indo visitar um tio e entregar três caixas de peças em São Paulo, a pedido de um amigo. O réu apresentou uma nota fiscal das supostas peças (fls. 33). Falaram que desconfiaram do volume informado na nota fiscal apresentada pelo réu que era diverso do volume das três caixas. Então, ao abrir as caixas transportadas pelo réu localizaram tabletes (tijolos) de cocaína e maconha.

Éder (policial), em juízo, narrou que receberam a informação que um Furgão branco, mencionando placa, bem como o horário que ia entregar drogas em Diadema e passaria pelo pedágio. Na informação não constava dados do condutor. Narrou que viram o veículo, fizeram acompanhamento, o réu acelerou e o abordaram. O condutor desceu, se identificou e no compartimento de trás havia caixas com drogas (maconha e cocaína). O réu alegou que não sabia que eram drogas. Disse que o réu apresentou uma nota, mas constava outro local de entrega (outro Município). As drogas (33 tabletes de maconha e 05 barras de cocaína) estavam em 3 caixas lacradas, bem grosseiramente, com durex. Não conhecia o réu anteriormente. No furgão não havia outras mercadorias. Falou que o réu passou pela praça de pedágio, passou e seguiu. Foram atrás, o réu acelerou ao perceber a viatura, mas depois obedeceu a ordem de

parada. Na informação não constava de onde vinham as drogas, mas o réu disse que vinha do Paraná.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Fernando. O réu alegou que um amigo num bar de São José do Pinhal (Paraná) pediu para transportar peças e apresentou nota fiscal (com local de entrega diferente do que ele falou), mas o volume que havia no Furgão era diverso do descrito nesta. Abriam as caixas, pois não parecia embalagem industrial (com fita marrom) e continha drogas (33 tabletes de cocaína e 5 barras de maconha). Disse que o réu informou que receberia R\$200,00. O réu ficou nervoso, mas não surpreso. Não conhecia o réu anteriormente. Informou que o réu falou que concordou em transportar por vir visitar o tio, acha que em SCS. Disse que o réu acelerou ao perceber o acompanhamento policial, mas depois obedeceu a ordem de parada.

O fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade e variedade de drogas apreendidas (fls. 25 - 33 tabletes de maconha e 5 tabletes de cocaína - com peso total aproximado de 19,142 kg), embaladas em tijolos, bem como a confissão judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa grande quantidade senão fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 36/38) e laudo definitivo (fls. 80/82).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 165/167).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o acusado em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima, por inexistirem elementos quanto a real situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela confissão judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

O M.P entendeu que deve ser afastado o tráfico privilegiado em razão da quantidade de drogas.

Há que se considerar que nos casos em que o autor do crime é considerado "mula" do tráfico, que foi contratado para transporte único, a jurisprudência do STJ e do STF é no sentido que apenas a grande quantidade de drogas, não conduz à conclusão de que integre ou se dedique a atividades criminosas, sendo possível a aplicação do benefício.

Nesse sentido: AgRg no HC 632857, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5.^a Turma do STJ, j. em 13.09.2022, publicado DJE de 16.09.2022.

O entendimento da Primeira Turma do STF no julgamento do AgRg no RHC n. 138.117/MS, MINISTRA ROSA WEBER, DJe de 6/4/2021, também é nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só,

fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido".

O mesmo entendimento é da 2.º Turma do STF no RHC 159494 AgR, Ministro Edson Fachin:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRANSPORTE DA DROGA NA CONDIÇÃO DE "MULA". AGENTE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO".

Observo que no RHC 155299 AgR / MS, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 08/09/2020, Publicação: 10/12/2020, Primeira Turma do STF, foi mantido o tráfico privilegiado para o caso de 20 quilos de drogas, caso similar ao deste feito: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. "MULA". INCIDÊNCIA DA MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGA. CONSIDERAÇÃO EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA. "BIS IN IDEM". 1. A condição de "mula" do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. A quantidade da droga não pode influenciar, simultaneamente, o aumento da pena-base e a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido". No caso em tela, o réu foi contratado para atuar como "mula" do tráfico, transportando razoável quantidade de drogas (fls. 25 - 33 tabletes de maconha e 5 tabletes de cocaína - com peso total aproximado de 19,142 kg.) entre Estados (os policiais afirmaram que o réu disse que trouxe do Paraná) por trabalhar com transporte rodoviário de cargas. Há que se observar que não ficou demonstrada a habitualidade na medida em que na informação recebida pelos policiais sequer havia dados da pessoa que transportava as drogas, o réu tem 38 anos e nunca foi processado, havendo em sua F.A, apenas este feito, confessou que o fez para pagar uma dívida com agiota e no apenso de liberdade provisória (proc. N.º 0002815-06.2022.8.26.0161) há comprovação de que trabalha com transporte rodoviário de cargas (fls. 24 do ap de liberdade provisória- com validade até 11.09.2025), que é empresário individual (fls. 25/28) e que efetivamente realiza esse trabalho fls. 37/140 e 221/288.

Logo, o réu preenche os requisitos para o tráfico privilegiado, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais, possui ocupação lícita, não havia denúncia mencionando seu envolvimento no tráfico, demonstrando que foi um ato isolado em sua via e que não integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas e inclusive confessou em juízo demonstrando arrependimento. Diminuo a pena de 1/3, considerando a quantidade de drogas apreendidas (fls. 25 - 33 tabletes de maconha e 5 tabletes de cocaína - com peso total aproximado de 19,142 kg), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de toneladas, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Apesar das ponderações do M.P., a grande quantidade de drogas, por si, só não permite concluir que o réu integra organização criminosa, uma vez que possui ocupação lícita. A quantidade de drogas por si só não afasta a redução, mas deve ser considerada no "quantum" da mesma.

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na

pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

Aumento a pena de 1/6, porque restou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, pois apreendido entorpecente em veículo que saiu do município de São José dos Pinhais, no Paraná, transitava em rodovia paulista e o destino final era Diadema, no Estado de São Paulo, conforme informado pelo réu na fase extrajudicial e pelos policiais.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, § 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO FILIPE AZAMBUJA à pena de 3 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Fls. 126, item "e": Diante da situação econômica do réu que declarou dever para agiota, concedo os benefícios da Justiça Gratuita, coloque-se a tarja indicativa. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto ao veículo IMP/Peugeot Boxer 350 MH, ano/, modelo 2011/2012, cor branca, placas EZQ4H65, apreendido (fls. 25), já periciado (fls. 153/157), não é caso de determinar o perdimento em favor da União, (art. 63 da Lei n.º 11343/06), uma vez que pertence a terceiro (pai do réu, conforme interrogatório e fls. 83), bem como que não é produto ou proveito do crime e era utilizado para atividade lícita (transporte rodoviário de cargas- docs no ap de liberdade provisória), não se justificando a perda do mesmo em virtude de uma única atividade ilícita demonstrada. A liberação do veículo poderá ser concedida após comprovação da propriedade. Oficie-se, após trânsito em julgado, que não interessa mais ao feito e que decorrido o prazo do art. 122 do CPP pode ser dado o destino pertinente. A liberação depende de demonstração da propriedade.

Em relação ao telefone celular marca Samsung, apreendido (fls. 25), já periciado (fls. 151/152), não há provas nos autos de que era utilizado ou fosse proveito do tráfico, pelo que oficie-se, desde logo, informando que não interessa mais ao feito e que decorrido o prazo do art. 122 do CPP pode ser dado o destino pertinente. A liberação depende de demonstração da propriedade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 51) e quanto ao veículo

como acima determinado e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 21 de setembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA